

포괄임금제의 성립 및 유효요건*

임 상 민

부산고등법원 고법판사

Formation and Validity Condition of Comprehensive Wage System

Sang-Min Lim

Busan High Court, High Court Judge

초록 : 포괄임금제는 현실적 편의성이란 측면에서 대법원 판례가 사업장의 관행을 용인함으로써 제도화되었다. 그러나 저임금, 장시간 근로를 고착시킴으로써 근로기준법이 정한 근로시간과 가산임금 내지 법정수당에 관한 제반 규정들을 사실상 무력화하는 제도라는 비판을 받아 왔다. 대법원은 그러한 비판을 어느 정도 수용하여 포괄임금제를 폭넓게 허용하던 초기와 달리 최근에는 여러 측면에서 포괄임금제를 제한적으로 해석하는 방향으로 판례를 판시해 오고 있다. 명시적 포괄임금계약과 달리 묵시적 포괄임금계약의 성립을 매우 제한적으로만 허용하거나, 근로시간 산정이 어려운 경우가 아니라면 차액 지급 청구를 인정하거나, 단체협약이나 취업규칙 외에 근로기준법도 근로자에게 불이익한지 여부를 판단하는 기준으로 제시하거나, 과거와 달리 계산의 편의와 근로자의 근로의욕 고취라는 표현의 사용을 자제하는 것 등이 그 예라고 볼 수 있다.

그러나 이러한 판례의 변화에도 불구하고 여전히 포괄임금제에 대한 비판이 강하게 존재하고 있고, 포괄임금제를 제도적으로 허용하는 판례로 인하여 상당수의 사업장에서 포괄임금제가 널리 성행하고 있는 것이 현실이다. 이러한 현실을 토대로 대한민국 정부는 포괄임금제를 엄격하게 규제하는 것을 내용으로 한 국정과제를 발표하기도 하였다.

이 논문에서는, 현재의 판례가 포괄임금제를 제한적으로 해석하는 방향으로 운용하고 있지만 여전히 근로시간과 가산임금 내지 법정수당에 대한 근로기준법의 강행규정성에 비추어 볼 때 포괄임금제에 대한 판례는 지금보다 훨씬 더 엄격하게 규제하는 방향으로 운용되어야 함을 밝히고자 하였다. 요약하면 다음과 같다. 정액수당제는 별론으로 하더라도 각종 가산임금 내지 법정수당 산정의 기초가 되는 기본임금(통상임금)을 특정할 수 없는 정액급제 포괄임금제는 무효로 보아야 한다. 차액 지급 청구를 부정하는 유형인 ‘근로시간 산정이 어려운 경우’란 ‘근로시간 산정이 불가능한 경우’로 해석되어야 한다. 포괄임금제의 성립요건 내지 유효요건을 논할 때에는 근로기준법의 강행규정성이 충실하게 고려되어야 한다.

Abstract : The comprehensive wage system was institutionalized by the Korean Supreme Court, which has approved the wage practices of the working place in considering the practical convenience aspect. However, the comprehensive wage system has been criticized as a system that

* 참고 “포괄임금계약의 성부와 유효성, 대상판결: 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 233586 판결” 『노동법실무연구』, 노동법실무연구회, 2021.을 기초로 내용을 수정, 보완, 추가, 삭제한 논문입니다.

effectively neutralizes all regulations on working hours, additional wages and legal allowances set under the Labor Standards Act by fixing low wages and long working hours. In accepting such criticism to some extent, the Korean Supreme Court has recently rendered decisions with a limited interpretation of the comprehensive wage system, contrary to the earlier decisions in which the formation and validity of comprehensive wage system were admitted broadly. Examples are as follows: 1) the formation of an implied comprehensive wage agreement has been recognized only on a very narrow basis, unlike the formation of express comprehensive wage agreement; 2) wage difference claims are recognized except in cases where it is difficult to calculate working hours; 3) not only collective agreement or employment rules but the Labor Standards Act has also been reviewed by the Court as a criterion in determining whether the comprehensive wage system is disadvantageous to employee or not; and 4) unlike the past, the Court has refrained from using the expression 'convenience of calculation' or 'encouraging the the employees' motivation to work'.

Despite such a shift in Court decisions, there still exists a strong criticism of the comprehensive wage system, which prevails in many work-places due to decisions that systematically admit the comprehensive wage system. Against this background, the Korean Government has also announced a national agenda dealing with strict regulations of the comprehensive wage system.

The purpose of this article is to demonstrate that even though the current decisions interpret the comprehensive wage system on a limited basis, the decisions need to be much stricter in light of mandatory rules of the Labor Standards Act on working hours, additional wages and legal allowances. The main points in this article are: 1) fixed total wage system should be regarded as invalid, because the fixed total wage system cannot specify the basic wage that serves as the basis for calculating various additional wages or legal allowances; 2) cases where it is difficult to calculate working hours (which is a type of a case that denies employees' wage difference claim) should be interpreted to be a case where it is impossible to calculate working hours; 3) lastly, when the requirement for the formation and validity of comprehensive wage system are discussed, the mandatory rule nature of the Labor Standards Act should be faithfully considered.

• 논문접수 : 2021. 10. 1.

• 심사 : 2021. 10. 10.

• 게재확정 : 2021. 11. 8.

I. 서설

‘노동자 올리는 포괄임금제 - 헐값에 팔리는 인간자유이용권’이라는 자극적인 언론 기사 제목¹⁾이 있다. 기사의 자극성이 기사의 객관성과 합리성을 담보할 수는 없지만, 포괄임금제가 노동현장에서 얼마나 많은 문제를 야기하는지에 대한 압축된 표현으로서는 제 기능을 다하고 있

는 것이 아닌가 싶다.

포괄임금제는 현실적 편의성이란 측면에서 대법원 판례가 사업장의 관행을 용인함으로써 제도화되었다. 그러나 현장에서 포괄임금제는 장시간 근로를 고착화하고, 휴가 제도를 무의미하게 하며, 실질 임금을 하락시킴으로써 근로기준법이 정한 근로시간과 가산임금 내지 법정수당에 관한 제반 규정들을 사실상 무력화하는 제

1) <https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=018&aid=000261797> (2021. 6. 21. 최종방문).

도라는 비판을 받아 왔다. 대법원은 그러한 비판을 어느 정도 수용하여 포괄임금제를 폭넓게 허용하던 초기와 달리 최근에는 여러 측면에서 포괄임금제를 제한적으로 해석하는 방향으로 판례를 판시해 오고 있다. 명시적 근로계약과 달리 묵시적 근로계약의 성립을 매우 제한적으로만 허용하거나, 근로시간 산정이 어려운 경우가 아니라면 차액 지급 청구를 인정하거나, 단체협약이나 취업규칙 외에 근로기준법에 근로자에게 불이익한지 여부를 판단하는 기준으로 제시하거나, 과거와 달리 계산의 편의와 근로자의 근로의욕 고취라는 표현의 사용을 자제하는 것 등이 그 예라고 볼 수 있다.

이러한 판례의 변화에도 불구하고 여전히 포괄임금제에 대한 비판이 강하게 존재하고 있고, 포괄임금제를 제도적으로 허용하는 판례로 인하여 상당수의 사업장에서 포괄임금제가 널리 성행하고 있는 것이 현실이다. 법적 안정성이라는 관점에서 현실로 만연한 제도²⁾를 함부로 손질해서는 안 되는 것인지는, 근로자에게 인간다운 삶을 보장하고자 하는 헌법의 정신을 고려해서 포괄임금제에 대한 대폭적인 개선, 개혁이 필요한 것인지에 대한 논의도 많다. 필자로서는 이러한 상반되는 입장을 조율하는 가장 중요한 기준은 근로기준법을 충실하게 준수하는 것이어야 한다고 생각한다. 법적 안정성이란 단순히

현실상황을 유지하는 것이 아니라 ‘법’에 따른 안정성이기 때문이기도 하고, 근로기준법이 근로자의 최저한의 생활수준을 보장하는 법이기 때문이기도 하다.

판례에 의하여 오래전부터 인정되어 온 포괄임금제의 성립요건과 유효성(유효요건)을 근로기준법의 시각에서 재조명하는 것은, 헌법과 근로기준법의 충실한 실천이라는 측면에서 대단히 중요한 작업일 것이다.

이하에서는 포괄임금제 일반론, 최근의 정부동향, 일본의 포괄임금제(비교), 포괄임금제의 문제점과 향후 개선방향 순으로 검토하고자 한다.

II. 포괄임금제 일반론

1. 개념과 의의

포괄임금제는 사용자와 근로자가 임금 산정방법을 정하면서 일정 항목의 임금을 따로 산정하지 않은 채 다른 항목의 급여에 포함시켜 일괄하여 지급하기로 하는 임금지급방법을 말한다.³⁾ 포괄임금제가 실시되기 위해서는 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 그 근거가 있어야 한다.⁴⁾

포괄임금제와 직접적인 관련이 있는 법령은 근로기준법 제17조와 제56조이다.⁵⁾ 근로기준법

2) 최근 실태조사에 의하면, 사무직 일반근로자에 대한 초과근로수당의 지급방식으로 포괄임금제를 채택하고 있는 기업이 41.3%에 달한다고 한다(김기선, “포괄임금제와 근로시간의 기록·관리” 『법과 정책연구』 제20집, 한국법정책학회, 2020., 129면).

3) 노동법실무연구회, 『근로기준법주해III』 제2판, 박영사, 2020., 275~276면.

4) 포괄임금제의 실시 근거 중 근로계약 47.1%, 취업규칙 및 취업규칙 유사 규정이 43.5%, 단체협약이 5.9% 정도를 차지한다고 한다(정동관 외, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, 한국노동연구원, 2016., 52면.)

5) 제17조(근로조건에 명시)

① 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

1. 임금
2. 소정근로시간
3. 제55조에 따른 휴일
4. 제60조에 따른 연차 유급휴가
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 근로조건

② 사용자는 제1항제1호와 관련한 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서

제17조는 임금, 소정근로시간 등에 대한 근로조건 명시에 관한 원칙을 정하고 있다.⁶⁾ 위 조문의 위임을 받은 근로기준법 시행령 제8조는 근로기준법 제93조 제1호부터 제12호까지의 규정에서 정한 사항 등을 명시해야 할 근로조건으로 정하고 있는데,⁷⁾ 여기에는 ‘임금의 결정·계산·지급방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급’과 ‘가족수당의 계산·지급방법’등이 포함된다.⁸⁾ 근로기준법 제56조는 통상임금을 기준으로 한 가산임금 지급의 원칙을 정하고 있다. 한편 근로기준법 제17조, 제56조 등은 강행규정이다.⁹⁾ 근로기준법 제17조, 제56조에 의하면, 사용자는 근로계약을 체결함에 있어 기본임금(통상임금)을 결정하고, 이를 기초로 하여 근로자가 실제로 근무한 근로시간에 따라 연장근로·야간근로·휴일근로 등이 있으면 그에 상응하는 연장근로수당·야간근로

수당·휴일근로수당 등의 법정수당을 가산하여 지급하여야 하고 구체적인 임금 결정·계산·지급 방법 등은 미리 명시되어 있어야 한다. 따라서 근로기준법은 임금의 질적 요소와 양적 요소를 반영하여 기본임금(통상임금)을 정한 후 이를 기초로 법정 제 수당을 계산하여 합산하는 방식을 임금산정방식으로 예정하고 있다. 그러나 사업장 현실에서는 이를 탄력적으로 운용하는 관행이 형성되어 왔고 판례가 그 관행을 허용하기 시작함으로써 포괄임금제 법리가 등장하게 된 것이다.

대법원은 1970년대에 ‘기본임금을 결정하고 이를 기초로 연장, 휴일, 야간근로수당 등 제 수당을 가산하여 지급하는 구조’에 대한 ‘예외’로서 사업장의 관행을 인정하기 시작하였고, 1990년대 중반 이후 ‘포괄임금제’라는 용어를 사용하

면을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다.

제56조(연장·야간 및 휴일 근로)

- ① 사용자는 연장근로(제53조·제59조 및 제69조 단서에 따라 연장된 시간의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 - ② 제1항에도 불구하고 사용자는 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
 1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
 2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100
 - ③ 사용자는 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에게 지급하여야 한다.
- 6) 근로기준법에서 근로계약에 임금 등 근로조건을 명시하도록 한 이유는, 사용자가 자신의 우월한 지위를 남용하여 구체적인 근로조건을 제시하지 아니한 채 근로조건 불확정 상태에서 근로자의 근로를 수령하는 것을 방지하기 위함이다(노동법실무연구회, 근로기준법주해Ⅱ, 박영사, 2010, 31). 사용자가 근로조건 명시 의무를 위반하면 500만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다(근로기준법 114조).
- 7) 제8조(명시하여야 할 근로조건)
법 제17조제1항 제5호에서 “대통령령으로 정하는 근로조건”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.
1. 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항
 2. 법 제93조제1호부터 제12호까지의 규정에서 정한 사항
 3. 사업장의 부속 기숙사에 근로자를 기숙하게 하는 경우에는 기숙사 규칙에서 정한 사항
- 8) 제93조(취업규칙의 작성·신고)
상시 10명 이상의 근로자를 사용하는 사용자는 다음 각 호의 사항에 관한 취업규칙을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다. 이를 변경하는 경우에도 또한 같다.
1. 업무의 시작과 종료 시간, 휴게시간, 휴일, 휴가 및 교대 근로에 관한 사항
 2. 임금의 결정·계산·지급 방법, 임금의 산정기간·지급시기 및 승급(승급)에 관한 사항
 3. 가족수당의 계산·지급 방법에 관한 사항
- (이하 생략)
- 9) 근로조건 명시 의무는 사용자에게 공법적인 의무만을 지운 것은 아니며, 근로계약의 내용이 불명확하거나 당사자 간에 다툼이 있다면, 명시 의무를 지는 사용자가 그 위험을 감수하도록 해야 한다는 것이 명시 의무의 사법적 효력이라고 보는 견해가 있다(강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토” 『노동법연구 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2008, 271~272면).

면서 그 법리를 형성하였다.¹⁰⁾ 선행 판례가 포괄임금제의 유효성을 인정하는 근거는 크게 두 가지이다.¹¹⁾ 첫째는, 계산의 편의와 근로자의 근로의욕 고취이다.¹²⁾ 둘째는, 정확한 실제 근로시간 산출이 어려운 경우의 합리적 해결이다.

포괄임금제에 관하여는 저임금, 장시간 노동을 방조한다는 측면에서 금지하거나 제한하여야 한다는 학계의 비판이 오랫동안 있어 왔다.¹³⁾ 판례도 그러한 측면을 고려하여 갈수록 포괄임금약정의 성립을 제한하거나 그 유효성을 엄격하게 해석해 오고 있다.¹⁴⁾

판례에 의하면, 연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당,¹⁵⁾ 연월차휴가수당 등이 포괄임금약정에 포함될 수 있다.¹⁶⁾ 휴일근로수당이나 연월차휴가근로수당에 대하여는 휴가를 사용하지 않을 경우에 발생하는 것임에도 사전에 이를

포함하는 것으로 약정하는 것은 모순이고, 휴가의 사용이 실질적으로 제약된다는 점을 근거로 반대하는 견해가 많지만,¹⁷⁾ 찬성하는 견해도 있다.¹⁸⁾ 휴일이나 휴가를 당초부터 사용하지 않기로 약정함을 전제로 포괄임금약정을 체결하는 것이어서 포괄임금약정의 허용범위를 이렇게까지 확대하는 것은 휴일이나 휴가에 관한 권리를 보장하고자 하는 근로기준법의 취지에 반하지 않나 생각한다. 퇴직금은 포괄임금에 포함될 수 없다는 것이 판례이다.¹⁹⁾

포괄임금제를 적용함으로써 최저임금에 미달하는 임금이 지급된 경우에는 해당 약정 부분은 최저임금법 위반으로 무효가 된다.²⁰⁾

소송법적 측면에서 보면, 포괄임금제는 초과근무 등에 따른 추가 법정수당 등의 지급을 구하는 소송에서, 사용자가 그 지급의무를 다하였

10) 최초의 판례는 대법원 1974. 5. 28. 선고 73다1258 판결(근로기간 중 연장근로, 야간근로, 휴일근로 및 월, 연차 유급 휴가근로 시간을 미리 예상하여 그 수당을 산출할 수 있는 것이고, 그와 같이 산출한 제수당을 근로계약서에 임금내역으로 표시할 수 있다고 할 것이며...)로 보인다.

11) 김형배, 「노동법」 제26판, 박영사, 2018., 453면 ; 노동법실무연구회, 「근로기준법주해 III」, 박영사, 2010., 162면 ; 홍준호, “포괄임금제의 유효성과 최소기준의 원칙”, 대법원 노동법실무연구회 세미나, 2019. 12., 11~19면.

12) 실제 근무실적에 따라 지급되어야 할 시간외, 야간 및 휴일수당 등을 근로시간 및 근로형태와 업무의 성질 등을 참작하고 계산의 편의와 직원의 근로의욕을 고취하는 뜻에서 매월 일정액을 제수당으로 지급하는 내용의 계약을 체결하였다 하더라도 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 이를 무효라고 할 수 없다(대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카32118 판결, 2001. 1. 16. 선고 99다37924 판결, 대법원 2005. 6. 9. 선고 2005도1089 판결 등 참조).

13) 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토” 「노동법연구」 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2008., 269면 ; 김홍영, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나, 2019. 12., 3면 ; 이석, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나, 2019. 12., 2면. 반면에, 포괄임금제 운영과 적용 과정에서 폐단의 여지가 있을 뿐 포괄임금제 자체는 근로자에게 불리한 제도라고 볼 수 없다면서 새로운 임금산정방식으로서 널리 활용될 필요가 있다는 견해도 있다(정재현, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, 한국노동연구원, 2016., 50~52면).

14) 임종률, 「노동법」 제19판, 박영사, 2021., 477면.

15) 휴일근로수당의 지급 대상이 되는 휴일에는 근로기준법 제55조의 주휴일뿐만 아니라 근로자의 날, 단체협약이나 취업규칙에서 휴일로 정한 날이 포함된다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2016다9704, 9711 판결).

16) 대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결, 대법원 2002. 6. 14. 선고 2002다16958 판결.

17) 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토” 「노동법연구」 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2008., 273면 ; 이광선, “포괄임금 약정의 효력과 문제점” 「저스티스 통권 제141호, 2014., 353~354면 ; 조임영, “포괄임금제에 의한 임금지급 계약의 성립요건” 「노동법률 제95호, 중앙경제사, 1999., 47면. 일본의 경우에는 시간외근로수당만이 포괄임금약정에 포함될 수 있는 것으로 본다.

18) 노동법실무연구회, 「근로기준법주해III」 제2판, 박영사, 2020., 295면 ; 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰” 「인권과 정의」 제347호, 대한변호사협회, 2005. 7., 73면.

19) 퇴직금이란 퇴직이라는 근로관계의 종료를 요건으로 하여 비로소 발생하는 것으로 근로계약이 존속하는 한 퇴직금 지급의무는 발생할 여지가 없는 것이다. 따라서 매월 지급받는 일당임금 속에 퇴직금이란 명목으로 일정한 금액을 지급하였다고 하여도 그것은 구 근로기준법 제28조에서 정하는 퇴직금 지급으로서의 효력은 없다고 할 것이다(대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결).

20) 대법원 2016. 9. 8. 선고 2014도8873 판결.

다는 항변의 형식으로 주로 활용된다.

2. 유형

포괄임금제의 유형으로는 ‘정액급제’와 ‘정액수당제’ 두 가지가 있다. 정액급제는, 기본임금을 미리 산정하지 않은 채 연장근로 등에 대한 제 수당까지 모두 합한 금액을 월 급여액이나 일당 임금으로 정하는 유형이다. 기본임금과 제 수당을 특정하지 않고 이들을 포함하여 월 급여액을 300만 원으로 정한 경우를 예로 들 수 있다. 정액수당제는, 제 수당 산정의 기준이 되는 기본임금을 특정하지만 제 수당은 구체적인 내역을 특정하지 않고 일정한 총액으로 지급하는 유형이다. 기본임금을 월 250만 원으로 하고, 제 수당은 기본임금과 별도로 월 50만 원으로 정한 경우를 예로 들 수 있다.

기본임금조차 정해지지 아니한 정액급제는 정액수당제보다 근로기준법 위반의 소지가 더 클 수 있다는 점에서 포괄임금제를 인정하는 경우라 하더라도 정액급제의 허용 여부에 관하여 견해가 대립한다.

부정설은, 기본임금과 제 수당의 지급액이 전혀 구분되지 않아 임금의 구성항목, 계산방법 및 지급방법에 대하여 사용자에게 명시할 의무를 부여하고 있는 근로기준법 제17조에 정면으로 위배되므로 무효라고 보는 견해이다.²¹⁾ 긍정설은, 근로계약 또는 노동조합과 맺은 자주적인 단

체협약에 기한 것이고 근로자에게 실질적으로 불이익을 주지 않는 이상, 근로기준법에 반하여 무효라고 할 것은 아니라고 보는 견해이다.²²⁾ 판례는 “기본임금을 미리 산정하지 아니한 채 제 수당을 합한 금액을 월급여액이나 일당임금으로 정하거나 매월 일정액을 제 수당으로 지급하는 내용의 이른바 포괄임금제에 의한 임금지급계약을 체결한 경우에 그것이 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 이를 무효라고 할 수 없다”²³⁾라고 판시한다. 이에 의하면 판례는 포괄임금제의 개념 자체로 정액급제를 한 유형으로 인정함으로써 유효설의 입장에 서 있다.²⁴⁾

근로계약이나 단체협약도 근로기준법의 강행규정성에 우선할 수 없는 한편(근로기준법 제3조, 제15조, 설령 근로자에게 실질적으로 불이익하지 않더라도 강행규정성 위반을 극복할 수 없다), 기본급을 확인할 수 없어 시간외 수당(연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당)의 등의 지급을 위한 전제인 통상임금을 특정할 수 없으면 그 자체로 근로자에게 불이익한 것으로 평가되어야 하므로(실질적으로 불이익하지 않다는 평가 자체가 불합리하다), 유효설 논거의 타당성에는 의문이 있다(뒤에 상술한다).

3. 성립요건

정액급제로서 또는 정액수당제로서 일정한

21) 김기선, “포괄임금제와 근로시간의 기록·관리” 『법과 정책연구』 제20집, 한국법정책학회, 2020., 146~147면 ; 김도형, “포괄임금약정에 관한 판례 법리의 검토” 『노동관계 비평』 제15호, 민주사회를 위한 변호사 모임, 2011., 189~191면.

22) 문형배, “포괄임금약정과 근로기준법 제61조” 『판례연구』 제11집, 부산판례연구회, 2000., 714면 ; 하갑래, 「근로기준법」, 전정 제25판, 중앙경제사, 2013., 445면.

23) 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결 등.

24) 판례는, 월급제 버스회사 배차원(80다2384 판결), 24시간 격일 근무 아파트 관리·경비원(83도2068 판결), 20일 이상 근무시 고정급을 받는 염전회사 현업원(89다카15939 판결), 1일 24시간 격일제 근무 신문사 운전직원(90다16245 판결), 제분회사 상하차반원(91다30828 판결), 아파트 경비원(92다33398 판결), 야간경비원(99다2881 판결), 성과급영업원(98다26385 판결), 경비업무(2003다66523 판결), 방송사의부체작요원(2004다66995, 67004 판결) 등의 사안에서 정액급제 포괄임금약정의 유효성을 인정하였다.

항목을 포괄하여 임금약정을 체결하면 포괄임금계약이 성립한다. 포괄임금제는 근로계약 당사자가 자유로이 약정할 수 있는 임금약정의 한 형태이므로, 근로형태의 특수성이나 근로시간의 산정이 어려운 경우에 한하지 않고 성립할 수 있다. 포괄임금제에 관한 약정이 성립하였는지는 근로시간, 근로형태와 업무의 성질, 임금 산정의 단위, 단체협약과 취업규칙의 내용, 동종 사업장의 실태 등 여러 사정을 전체적·종합적으로 고려하여 구체적으로 판단하여야 한다. 비록 개별 사안에서 근로형태나 업무의 성격상 연장·야간·휴일근로가 당연히 예상된다고 하더라도 기본급과는 별도로 연장·야간·휴일근로수당 등을 세부항목으로 나누어 지급하도록 단체협약이나 취업규칙, 급여규정 등에 정하고 있는 경우에는 포괄임금제에 해당하지 아니한다. 그리고 단체협약 등에 일정 근로시간을 초과한 연장 근로시간에 대한 합의가 있다거나 기본급에 수당을 포함한 금액을 기준으로 임금인상률을 정하였다는 사정 등을 들어 바로 위와 같은 포괄임금제에 관한 합의가 있다고 선불리 단정할 수는 없다.²⁵⁾

포괄임금약정은 명시적 합의는 물론 묵시적 합의에 의하여도 성립할 수 있다. 그러나 판례는 포괄임금제가 법이 예정하는 원칙적인 임금 지급 형태가 아니라는 점을 고려하여, “단체협약이나 취업규칙 및 근로계약서에 포괄임금이

라는 취지를 명시하지 않았음에도 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정이 성립하였다고 인정하기 위해서는, 근로형태의 특수성으로 인하여 실제 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 곤란하거나 일정한 연장·야간·휴일근로가 예상되는 경우 등 실질적인 필요성이 인정될 뿐 아니라, 근로시간, 정하여진 임금의 형태나 수준 등 제반 사정에 비추어 사용자와 근로자 사이에 정액의 월급여액이나 일당임금 외에 추가로 어떠한 수당도 지급하지 않기로 하거나 특정한 수당을 지급하지 않기로 하는 합의가 있었다고 객관적으로 인정되는 경우이어야 한다”라고 판시함으로써,²⁶⁾ 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정의 성립을 엄격하게 제한한다. 학설 중에는 명시적 합의에 의한 포괄임금약정만 허용될 뿐 묵시적 합의에 의한 포괄임금약정은 금지된다는 견해가 있다.²⁷⁾

4. 유효요건

가. 근로시간 산정이 어려운 경우와 그렇지 아니한 경우의 구별

대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결은 포괄임금제의 유효요건에 대하여 명시적인 법리를 판시하였다.²⁸⁾ 이에 의하면, 근로시간 산정이 어려운 경우와 그렇지 아니한 경우를 구별

25) 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 233586 판결. 이 판결 사안에서는 임금협정서에 ‘상기 월 임금에는 ~ 제반 법정수당이 포함된 금액이며’, ‘포괄임금방식에 의거 1일 19시간을 기준으로 산정하고 임금을 지급’, ‘임금제도는 격일제 운행에서 발생할 수 있는 모든 수당을 포함한 포괄임금제로 하고, 임금조건표의 임금은 임금 지급의 편의를 위해 임금 항목을 구분한 것일 뿐이라는 점을 상호 인정’ 등의 문구가 기재되어 있었음에도 불구하고 포괄임금약정의 성립을 부정하였다. 이 판결에 대한 구체적인 평석은, 임상민, “포괄임금약정의 성부와 유효성, 대상판결: 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 233586 판결” 『노동법실무연구』, 노동법실무연구회, 2021., 239~252면 참조.

26) 대법원 2016. 10. 13. 선고 2016도1060 판결.

27) 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계” 『노동법학』 제29호, 한국노동법학회, 2009., 353면.

28) 근로시간의 산정이 어려운 경우가 아니라면 달리 근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 앞서 본 바와 같은 근로기준법상의 근로시간에 따른 임금지급의 원칙이 적용되어야 할 것이므로, 이러한 경우에도 근로시간 수에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하는 내용의 포괄임금제 방식의 임금 지급계약을 체결하는 것은 그것이 근로기준법에 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 이상 허용될 수 없다. 한편 구 근로기준법 (2007. 4. 11. 법률 제8372호로 전부 개정되기 전의 것) 제22조(현행 법 제15조)에서는 근로기준

하여 다음과 같이 포괄임금제의 유효요건을 설정한다.

근로시간 산정이 어려운 경우(근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우를 포함)에는, 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다. 이와 같이 포괄임금제가 유효한 이상, 근로자는 차액에 대한 정산청구를 할 수 없다.

근로시간 산정이 어렵지 않은 경우에는, 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 부분은 효력이 없다.²⁹⁾ 이에 따라 근로자는 근로기준법에 따라 산정한 법정수당과의 차액에 대한 정산청구를 할 수 있다.

대법원 2008다6052 판결은, 포괄임금제는 근로기준법이 예정하는 원칙적인 방식과는 다른 방식으로 임금계약을 약정할 수 있다는 것이지 근로기준법상의 근로시간의 규제에 대한 예외를 인정하는 것은 아니라는 점을 명백히 하였다는 점에서도 의의가 있다.³⁰⁾ 다만, 근로시간 산정이 어렵지 않은 경우에 체결된 포괄임금약정 중 정액수당제에 대하여는 명시적으로 판단 기준을 제시하고 있지만, 정액금제의 경우에는 어떠한 기준으로 그 유효성을 판단할 것인지에 대하여 명시적으로 판단하지 아니하여 향후 논의의 여지를 제공하고 있다.

나. 근로시간 산정이 어려운 경우

대법원 2008다6052 판결은 포괄임금약정을 근로시간의 산정이 어려운 경우와 이에 해당하지 않는 경우를 구분하여 그 유효성을 달리 판단하고 있으므로, ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’가 어떤 경우를 의미하는지가 중요한 판단 기준이 되었다.

대법원 2008다6052 판결은 이와 관련하여 구체적인 기준을 제시하고 있지 않으므로, ‘근로시간의 산정’이라는 표현의 문언적 의미와 포괄임금제의 제도적 의의를 고려하여 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’ 또는 ‘근로기준법상의 근로시간에 관한 규정을 그대로 적용할 수 없다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우’에 해당하는지 여부를 사안에 따라 구체적으로 판단할 수밖에 없다. 다만, 근로시간의 산정이 가능한 경우에, 근로시간의 산정이 어렵다고 보아서 근로기준법에 따라 산정된 임금보다 적은 금액을 지급하도록 포괄임금약정이 이루어졌음에도 불구하고 차액 지급 청구를 할 수 없다고 한다면, 이는 근로조건의 최저기준을 정한 근로기준법의 강행규정성에 반할 수 있으므로, 근로시간의 산정이 어렵다는 판단은 엄격하게 이루어져야 할 것이다.

선행판례가 근로시간의 산정이 어려운 경우로 인정해 온 사례는, ① 근로시간 산정이 어려운 사업장 외 근로, ② 근로시간 산정이 어려운 사업장 내 근로, ③ 감시적·단속적(斷續的) 근로,³¹⁾ ④ 일당도급제 근로 등으로 나뉜다.

법에 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 하면서(근로기준법의 강행성) 그 무효로 된 부분은 근로기준법이 정한 기준에 의하도록 정하고 있으므로(근로기준법의 보충성), 근로시간의 산정이 어려운 등의 사정이 없음에도 포괄임금제 방식으로 약정된 경우 그 포괄임금에 포함된 정액의 법정수당이 근로기준법이 정한 기준에 따라 산정된 법정수당에 미달하는 때에는 그에 해당하는 포괄임금제에 의한 임금지급계약 부분은 근로자에게 불이익하여 무효라 할 것이고, 사용자는 근로기준법의 강행성과 보충성 원칙에 의해 근로자에게 그 미달되는 법정수당을 지급할 의무가 있다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결).

29) 만일 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 부분이 없으면 포괄임금약정은 유효하다. 근로기준법이 정한 근로시간에 관한 규제를 위반하는 부분에 한하여 근로시간에 관한 강행규정이 보충적으로 적용된다.

30) 박순영, “근로기준법상 근로시간의 규제와 포괄임금제” 『대법원판례해설』 제83호, 법원도서관, 2010., 826면.

31) 감시적 근로는 감시 업무를 주업무로 하며 상대적으로 정신적·육체적 피로가 적은 업무를 말한다(근로기준법 시행규칙 제10조 제2항). 단속적 근로는 근로가 간헐적·단속적으로 이루어져 휴게시간 또는 대기시간이 많은 업무를 말

근로시간 산정이 어려운 사업장 외 근로에 대하여 포괄임금제의 유효성을 인정한 선례로는, 사업장 밖에서 장거리 운행을 하는 트랙터 트레일러 운전원 사례,³²⁾ 운행 경로 교통 상황 운전사의 근무 태도 등에 따라 근무시간이 근로자별로 일정하지 않아 정확한 근로시간을 파악하기 어려운 시외버스 운전사 사례³³⁾ 등을 들 수 있다.

근로시간 산정이 어려운 사업장 내 근로에 대하여 포괄임금제의 유효성을 인정한 선례로는, 매일의 기상 조건에 따라 근로시간이 달라지는 염전회사 직원 사례,³⁴⁾ 제분 회사 상하차 근무 사례,³⁵⁾ 매일의 작업시간과 휴식시간이 불규칙한 해외 건설현장 관리 사례,³⁶⁾ 방송·드라마 제작 진행과 기록을 맡은 외부 제작 요원 사례³⁷⁾ 등을 들 수 있다.

감시적·단속적(斷續的) 근로에 대하여 포괄임금제의 유효성을 인정한 선례로는, 아파트 경비 업무 사례,³⁸⁾ 버스회사 배차 업무 사례,³⁹⁾ 야간 경비 업무 사례,⁴⁰⁾ 보일러 운전기사 사

례⁴¹⁾ 등을 들 수 있다.⁴²⁾

일당도급제 근로에 대하여 포괄임금제의 유효성을 인정한 선례로는, 택시운전사 사례,⁴³⁾ 일당으로 임금이 지급되는 국가기관의 순수한 일용직 잡급 사례,⁴⁴⁾ 한국방송공사 외부제작요원 사례,⁴⁵⁾ 홍익회 성과급영업원 사례⁴⁶⁾ 등을 들 수 있다.

다. 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당할 것

대법원 2008다6052 판결은 근로시간 산정이 어려운 경우에 체결된 포괄임금약정의 경우 그것이 근로자에게 불이익이 없고 여러 사정에 비추어 정당하다고 인정될 때에는 유효하다고 판시하였다.

종래의 판례는, 포괄임금제에 있어 근로자의 불이익 여부를 판단하는 기준으로 단체협약과 취업규칙을 제시한 바 있다.⁴⁷⁾ 근로자 불이익

한(근로기준법 시행규칙 제10조 제3항). 감시적·단속적 근로는 통상적인 노동에 비하여 일반적으로 노동의 밀도가 낮고, 신체적 동작의 부담이나 정신적, 신경적 부담이 가볍고 신체의 피로나 정신의 긴장이 적어서 노동시간 등에 관한 근로기준법의 규제를 받지 않더라도 근로자의 보호에 지장이 없기 때문에 근로기준법 제63조 제3호는 감시·단속적 근로에 종사하는 자에 대하여 사용자가 고용노동부장관의 승인을 받으면 근로기준법의 근로시간 등에 관한 적용을 제외하도록 규정하고 있다.

32) 대법원 1982. 12. 28. 선고 80다3120 판결.

33) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90다카6934 판결.

34) 대법원 1990. 11. 27. 선고 89다카15939 판결.

35) 대법원 1992. 2. 28. 선고 91다30828 판결.

36) 대법원 1991. 4. 23. 선고 89다카32118 판결.

37) 대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다66995,67004 판결.

38) 대법원 1983. 10. 25. 선고 83도1050 판결.

39) 대법원 1982. 3. 9. 선고 80다2384 판결.

40) 대법원 1999. 5. 28. 선고 99다2881 판결.

41) 대법원 2002. 8. 27. 선고 2000다65383,65390 판결.

42) 종래 판례가 ‘감시적·단속적 근로’를 근로시간의 산정이 어려운 경우의 예시로 들어 온 것은 맞으나, 감시적·단속적 근로라고 하여 일반적으로 근로시간의 산정이 어려운 경우에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 감시적·단속적 근로에 해당한다고 하여 쉽게 포괄임금계약의 유효성을 인정해서는 안 된다는 견해로는, 김진석, “포괄임금계약의 허용범위” 『노동법실무연구 제1권, 사법발전재단, 2011.』, 440~441면.

43) 대법원 1985. 3. 26. 선고 84도1861 판결.

44) 대법원 1987. 6. 9. 선고 85다카2473 판결.

45) 대법원 2006. 4. 28. 선고 2004다66995,67004 판결.

46) 대법원 1999. 6. 11. 선고 98다26385 판결.

47) 포괄임금제에 의한 임금지급계약이 근로자에게 불이익이 없어야 한다는 것은 단체협약이나 취업규칙에 구체적인 임금지급 기준 등이 규정되어 있는 경우에 그러한 규정상의 기준에 비추어 보아 불이익하지 않아야 한다는 것을 의

여부의 판단기준에 근로기준법도 포함되는지에 관하여 학설이 대립하였다.⁴⁸⁾ 이러한 가운데 2008다6052 판결은 근로시간의 산정이 어렵지 않은 경우에 근로기준법을 기준으로 불이익 여부를 판단하여야 함을 명시함으로써 긍정설의 입장을 취하고 있다. 근로기준법의 강행규정을 고려하면 긍정설이 타당하다 할 것이다.

제반 사정에 비추어 정당하다는 것은, 단체협약, 취업규칙, 동일노동 동일임금 원칙 외의 요소들, 예컨대 포괄임금제 이전의 연장근로수당 등의 지급실태, 동종업계 근로자의 임금수준 등 기타 사정을 고려하여 정당해야 한다는 취지이다.⁴⁹⁾

III. 최근의 정부 동향

1. 주요 국정과제

2017. 8. 대한민국 정부가 발표한 100대 국정과제 중 71번째가 ‘휴식 있는 삶을 위한 일·생활의 균형 실현(고용노동부)’이고, 그 주요내용에는 ‘포괄임금제 규제’가 포함되어 있다.

2. 포괄임금제 사업장 지도지침(안)⁵⁰⁾

고용노동부는 위와 같은 주요 국정과제를 실천하기 위하여 2017. 10. 포괄임금제 사업장 지도지침을 작성하였다. 이에 의하면, 포괄임금제는 근로기준법의 임금과 근로시간 규정을 사실상 형해화하는 관행으로서 근로시간 산정이 실제로 어려운 경우 등 엄격한 요건 아래 극히 제

한적으로 인정되어야 하는 임금지급 방식이나, 현장에서는 계산상의 편의, 초과근로 예정 등 다양한 이유를 들어 근로기준법의 원칙과 판례가 허용하는 범위를 넘어 매우 광범위하게 활용되고 있어 이를 제한할 필요가 있음을 배경으로 한다고 기재하고 있다.

위 지도지침의 내용 중 유의할 만한 부분은 포괄임금제의 유효요건 부분이다. 이를 요약하면 아래와 같다.

① 포괄임금제는 근로시간 산정이 어려운 경우에 한하여 예외적으로 인정되고, 근로시간 산정이 어렵지 않으면 명시적 합의가 있어도 무효이다. 원칙적으로 근로시간 산정이 어려운 경우란 근로시간의 산정이 물리적으로 아예 불가능하거나 거의 불가능한 경우만을 의미한다. 단순히 근로시간 관리가 곤란한 경우는 근로시간 산정이 어려운 경우에 해당하지 않으므로 계산상의 편의나 직원의 근무의욕 고취라는 목적으로 포괄임금제를 활용하는 것은 허용될 수 없다. 운수업의 경우라면 장거리 운행, 불확정적인 운행일정 등으로 인해 근로와 휴식의 구분이 어려운 경우이어야 한다. 사용자가 근로자의 근로시간을 구체적으로 관리하는 경우는 근로시간 산정이 어려운 경우로 볼 수 없다(배차 표에 따라 출발시간과 운행종료시간이 정해져 있는 정기노선버스 등).

② 근로시간 산정이 어려운 예외적인 사유가 인정되는 경우에도 그에 더하여 반드시 포괄임금제에 대한 명시적 합의가 있어야 한다. 즉 근로계약서에 포괄임금제를 적용한다는 내용이 명시적으로 기재되어 있어야 한다. 단체협약에

미하는 것이다. (중략) 이 사건에서 일용직 근로자들에게 지급된 임금이 취업규칙에 비추어 불이익한지의 여부는 그 임금액이 일용직 근로자들에게 적용되는 위 근로계약서의 내용에 비추어 불이익한지의 여부에 의하여 판단하여야 하고 일반 사원들의 임금과의 비교는 반드시 필요한 것이 아니다(대법원 1998. 3. 24. 선고 96다24699 판결).

48) 노동법실무연구회, 「근로기준법주해Ⅲ」 제2판, 박영사, 2020., 167면.

49) 노동법실무연구회, 「근로기준법주해Ⅲ」 제2판, 박영사, 2020., 294면.

50) 고용노동부에서 내부적으로 마련한 것이다. 고용노동부에서 수차례 공표를 시도하였으나 경영계의 반발과 후폭풍 등을 고려하여 아직 공표하지 못하고 있다.

포괄임금제 적용에 대한 근거가 있는 경우에도 개별 근로자의 명시적 동의를 얻어야 한다. 근로계약서에 임금산정식만 제시하는 것으로 근로자가 내용을 알고 합의했다고 보기 어렵고, 포괄임금제라는 문구가 명시되거나 법정수당이 실제 근로와 무관하게 기본급이나 정액수당에 포함되어 지급된다는 내용이 기재되어야 한다. 단순히 근로자가 아무런 이의 없이 급여를 수령하였다는 사실만으로는 합의가 있었다고 인정하기 어렵다. 단체협약 또는 취업규칙 등에 기본급과는 별도로 법정수당을 각 항목별로 나누어 지급하도록 규정하고 있다면 노사 간 일정시간을 연장근로시간으로 간주하기로 하는 합의가 있더라도 이를 포괄임금제에 대한 합의로 볼 수 없다.

IV. 일본의 포괄임금제

포괄임금제에 관한 일본의 판례와 통설은 포괄임금제에 대한 엄격한 규제를 지향한다.⁵¹⁾ 일본에서도 포괄임금제 관련 분쟁이 많은데, 장시간 일하더라도 정해진 금액 범위에서만 가산임금을 지급하도록 가산임금의 상한선을 긋는 수단으로 자리매김된 탓에 인건비를 억제하기 위한 수단으로 활용되어 온 것이 주요 원인이라는 지적이 있다.⁵²⁾

일본 판례, 통설에 따른 포괄임금제(시간외근로수당을 포함하여 임금 총액을 약정하는 것)의 유효요건은, ① 기본급 중 시간외근로수당에 해당하는 부분이 명확히 구분되고 그 성격이 연장근로수당이라는 점에 대한 합의가 존재하여야 하고, ② 일본 노동기준법이 정하는 계산방법에 따라 계산한 금액이 합의에 따른 금액보다 고액인 경우에는 그 차액을 당해 임금 지급기에 지급한다는 점에 대한 합의가 존재하여야 한다는 것이다.⁵³⁾ 이를 정액급제와 정액수당제로 나누어 분설하면 아래와 같다.

1. 정액급제: 무효

가산임금을 포함하여 임금이 설정되어 있는 정액급제의 경우, 법이 정한 수당이 지불되고 있음을 확인할 수 있어야 한다. 즉 합의의 내용상 통상임금부분과 가산임금부분을 구별할 수 있어야 한다.⁵⁴⁾ 예컨대, 기본급 30만 엔에 고정수당을 포함한다는 식으로 정하는 경우, 통상임금부분과 가산임금부분을 구분할 수 없어, 일본 노동기준법 제37조를 참탈하여 무효이다. 이와 같이 구별이 안 되는 경우에는 기본급 30만 엔 전액이 통상임금에 해당하게 된다.⁵⁵⁾ 정액수당에 관하여도, 가산임금부분과 다른 성질의 임금부분이 혼재하여 판별할 수 없는 경우에는 마찬

51) 최석환, “일본의 근로시간 제도개혁과 포괄임금제” 『아주법학』 제12권 제2호, 아주대 법학연구소, 2018., 228면.

52) 최석환, 위의 논문, 229면.

53) 최석환, 위의 논문, 230면.

54) 最高裁 2012. 3. 8. 平2(受)1186号(체크재판 판결). 위 판결 사안을 간략히 소개하면, 기본급을 월 41만 엔으로 하여 월간총근로시간이 180시간을 초과하는 경우에는 1시간당 일정액을 별도로 지급하고, 140시간 미만인 경우에는 1시간당 일정액 감액하는 내용으로 약정한 근로계약에서, ① 위 각 시간외근로가 행해져도 위 기본급 자체가 증액되지 않고, ② 위 기본급 중 일부가 다른 부분과 구별되어 같은 항이 정하는 시간외 할증임금으로 되는 등의 사정이 보이지 않는 한편, 위 할증임금의 대상으로 되는 한 달의 시간외근로의 시간수는 각 월에 근무해야 할 일수의 차이 등에 의해 상당히 크게 변동할 수 있고, 위 기본급에 관하여 통상 근로시간의 임금에 해당하는 부분과 위 할증임금에 해당하는 부분을 구별할 수 없는 사정 하에서는, 근로자가 시간외근로를 한 달에 대하여 사용자는 근로자에게 월간총근로시간이 180시간을 초과하는 달의 근로시간 중 180시간을 초과하지 않는 부분에서의 시간외근로 및 월간총근로시간이 180시간을 초과하지 않는 달의 근로시간에서의 시간외근로에 관해서도, 기본급과 별도로 노동기준법 37조 1항이 정하는 할증임금을 지급할 의무를 진다고 판단하였다. 한편 위 판결의 보충의견은, 근로계약상 정해져 있을 뿐만 아니라, 지급시에도 시간외근로시간 수와 시간외근로수당 금액이 명시되어야 한다고 판시하고 있다.

55) 최석환, 앞의 논문, 231면.

가지로 무효이다.

2. 정액수당제와 차액지급

포괄적으로 약정한 정액수당이 법이 정한 금액에 미달되는 경우에, 차액을 추가로 지급하지 않으면 당연히 노동기준법 위반으로 된다. 이에 관련하여, 정액수당제의 유효요건으로 법이 정한 금액과의 차이가 있는 경우, 차액이 소정 임금지급기에 지급되도록 합의되어 있을 것을 요한다는 취지로 판시한 판례도 있다.⁵⁶⁾ 합의가 없더라도 일본 노동기준법 규정에 의하여 차액이 지급되어야 하므로 독립적인 요건으로 해석할 것은 아니라는 견해도 있다. 이에 반하여 정액수당제를 채용함으로써 시간외 수당 지급을 마친 것으로 되어 가산임금규제 잠탈을 조장하기 쉽다는 문제점, 근로자가 지급되어야 할 차액을 계산하여 청구하는 것의 어려움, 근로계약 당사자 사이의 계약내용에 대한 이해 촉진이라는 근로계약의 기본원리 등을 고려하면, 관련 행위규범을 따를 것을 요구하는 것에 타당성이 있다는 견해도 있다.⁵⁷⁾

3. 근로시간의 산정이 어려운 경우에 대한 독자적인 요건성 부정

일본의 포괄임금제는 우리나라와 달리 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’라는 유효요건을 따로 설정하지 않는다. 근로시간의 산정이 어려운

경우와 근로시간 산정이 어렵지 아니한 경우를 구별하여 포괄임금제 유효요건을 달리 하는 것은 우리나라 판례의 독자적인 규제 방향이라고 볼 수 있다. 그러나 일본의 포괄임금제 법리에서는, 근로시간의 산정이 어려운 경우인지를 불문하고 차액 지급 청구를 인정하고 있고, 정액금제의 유효성도 부정하고 있어, 근로시간의 산정이 어려운 경우로 유효요건을 제한할 유인 내지 동기 자체가 없다고 볼 수 있다.

V. 현행 포괄임금제의 문제점과 향후 개선방향

1. 인정근거와 근로기준법의 강행규정성

선행판례가 꽤 폭넓게 포괄임금제를 인정해 온 배경에는 두 가지 있다. 하나는, 계산의 편의와 근로자의 근로의욕 고취를 하나의 근거로 인정했다는 점이다. 계산의 편의와 근로자의 근로의욕 고취라는 측면에서 보면, 관점에 따라 포괄임금제는 근로자에게도 이익이 되는 제도이지 일방적으로 사용자에게 유리한 제도가 아니므로 포괄임금제를 허용하거나 그 범위를 넓게 인정하는데 긍정적으로 작용한다. 또 하나는, 근로기준법의 강행규정성보다 현실세계에서의 구체적 타당성을 중시한다는 점이다. 즉 판례는 포괄임금제를 인정함으로써 현실세계의 구체적 타당성을 확보하기 위해 근로기준법의 강행규정성을 후퇴시키는 것을 용인한다.

56) 最高裁 1988. 7. 14. 昭63(オ)267号(소리기제 사건). 일본 최고재판소는 소리기제 사건에서 “월 15시간의 시간외 근로에 대한 할증임금을 기본급에 포함하는 취지의 합의가 있다고 하더라도 그 기본급 중 할증임금에 해당하는 부분이 명확하게 구분되어 합의가 이루어지고, 노동기준법 소정의 계산방법에 따른 금액이 그 금액을 상회할 때에는 그 액을 당해 임금 지급기에 지급할 것임이 합의되어 있는 경우에만 그 예정 할증임금 부분을 당해 월의 할증임금 중 일부 또는 전부로 할 수 있다”라고 판시하였다. 한편 격일제 택시기사의 근무형태와 관련하여 통상 근로시간 임금에 해당하는 부분과 시간외 및 야간 할증임금에 해당하는 부분을 판별할 수 없는 정액급제 포괄임금제(歩合給制)는 비록 시간외 및 야간 할증임금을 포함하는 고율의 포괄임금을 지급하고 있다고 하더라도 무효라는 취지의 판결로는, 最高裁 1994. 6. 13. 平3(オ)63号(고치현관광 사건)가 있다. 다만 전체적으로 보면 차액정산에 대한 명시적인 합의를 포괄임금제의 독립요건으로 보지는 않는 듯하다(최석환, 위의 논문, 232면).

57) 荒木尙志, 「労働法」, 第三版, 有斐閣, 2016, 168면.

그런데 이러한 두 가지 배경 모두 그 정당성에 의문이 있다.

먼저 계산의 편의는 오로지 근로계약 체결시점에서만 작용할 뿐이다. 그런데 근로계약 체결시점에서 편리함을 확보하고자 실제 근로시간이나 임금에 대하여 근로기준법이 정한 최저기준이 무시된다면 이를 들어 근로자에게 이익이 된다고 평가할 수는 없을 것이다. 또한 법이 정한 근로시간과 임금이 제대로 준수되어야 근로자의 근로의욕이 고취되지, 법이 정한 근로시간과 임금조차 지켜지지 않아 장시간 저임금 근로가 용인되는 결과가 초래됨에도 불구하고 근로의욕이 고취된다는 것은 이해하기 어려운 논리이다.

물론 포괄임금제로 인하여 사용자로 하여금 근로계약을 체결하도록 유인하는 측면에서 보면 근로계약을 체결하지 못하여 생계의 곤란을 겪는 것보다 근로자에게 유리하므로 구체적인 타당성에 부합한다는 반론을 고려해 볼 수는 있다. 그러나 사용자로 하여금 근로계약의 체결을 통한 일자리 창출을 유도한다는 긍정적 효과가 있더라도 그 과정에서도 여전히 지켜져야 하는 것이 강행규정이다. 강행규정이란 당사자의 합의로 위반을 정당화할 수 없는 규정이기 때문이다. 한편 근로기준법상 근로시간과 임금에 대한 규정이 바로 그러한 강행규정이다. 그리고 근로기준법이 근로시간과 임금에 대한 강행규정을 두고 있는 것은 최저한의 휴식과 임금을 확보함으로써 헌법이 기본권으로 정하고 있는 근로자의 인간다운 생활을 보장하기 위함이다. 그런데 대법원은 포괄임금제를 폭넓게 인정함으로써 근로기준법상 강행규정을 더 이상 강행규정이 아니도록 해석하고 있는 것이다.

2. 정액급제의 유효성

기본임금을 명시하지 않는 정액급제에서는

계약의 내용으로부터 기본임금을 특정할 수 있는 경우가 아닌 이상, 시간외 근로수당 등 제반수당을 산정할 수가 없어 근로기준법이 정하는 가산임금이 준수되는지를 확인할 수 없다. 따라서 정액급제 하에서는 당초부터 가산임금 관련 근로기준법 위반 주장을 할 수가 없다. 한편 가산임금이 준수되는지를 확인할 수 없다는 것은 가산임금을 정하고도 이를 준수하지 않는 것보다 그 위법성이나 비난가능성을 무겁게 평가하여야 한다. 이는 도로교통법이 음주운전죄보다 음주측정거부죄의 형량을 더 높게 정하는 것과 같은 이치이다. 일본의 판례, 통설처럼, 정액급제를 그 자체로 무효로 봄으로써 가산임금 관련 근로기준법 위반을 엄격하게 통제하여야 하고, 차액 지급 청구를 원천적으로 봉쇄하는 것을 어떤 경우에도 허용하지 않아야 한다. 오히려 정액급제 포괄임금약정에 따라 근로계약의 내용으로부터 기본임금을 특정할 수 없으면, 법령을 위반한 사용자에게 불리하게, 약정한 정액급을 기본임금으로 간주하는 해석이 필요하다 할 것이다.

3. ‘근로시간 산정이 어려운 경우’의 의미

현행 판례상으로는, ‘근로시간 산정이 어려운 경우’에 해당하는지 여부가 포괄임금제의 유효성을 가르는 가장 중요한 기준이라고 볼 수 있다. 근로시간 산정이 어려우면 포괄임금약정은 유효하고 나아가 차액 지급 청구가 봉쇄되므로 근로시간 관련 근로기준법상 강행규정의 적용이 사실상 배제되기 때문이다.

그런데, 근로시간 산정이 어렵다는 것은 사실인정의 영역이기도 하지만 평가의 영역이기도 한데 객관적인 평가가 결코 쉽지 않다. 한편 근로시간 산정이 어렵다는 평가를 어느 시점에서 할 것인지도 문제될 수도 있다. 포괄임금약정의 유효요건이므로 일용 근로계약 체결시점에서

평가되어야 할 것이다. 그러나 근로계약 체결시점에서는 어렵다고 평가되었는데 이후 실제 근로를 제공하는 시점 또는 임금을 지급하는 시점에서 어렵지 않다고 평가될 때 어떻게 할 것인가? 그리고 근로시간 산정이 어려운지 여부와 가능한지 여부는 그 자체로 개념이 다르다. 근로시간 산정이 가능하기는 한데 어려운 경우에 또 어떻게 처리할 것인가?

결국 근로기준법상 근로시간에 관한 강행규정성을 존중한다면, 근로시간 산정이 어렵더라도 가능한 이상 근로시간에 관한 강행규정을 적용하여야 하고, 나아가 비록 근로계약 체결시점에서 근로시간 산정이 불가능하더라도 이후 근로를 제공하는 시점 내지 임금을 지급하는 시점에서 근로시간 산정이 가능한 이상 역시 근로시간에 관한 강행규정을 고려하여 근로시간 산정이 불가능하지 않다고 보아야 한다.

따라서 근로시간 산정이 어렵다는 이유로 근로기준법상 근로시간에 관한 강행규정의 적용을 배제하는 현행 판례 법리는, 근로기준법상 근로시간에 관한 강행규정성을 고려하면, 근로계약 체결시점, 근로제공시점, 임금지급시점 중 어느 시점에서 보더라도 ‘근로시간의 산정이 불가능한 경우’로 제한적으로 해석되어야 한다.⁵⁸⁾ 판례는, ‘근로자에게 불이익이 없을 것’을 포괄임금제의 유효요건으로 정하고 있으므로 근로자의 이익을 도모하기 위한 강행규정인 근로기준법이 불이익 여부에 대한 판단기준이 되어야 한다는 점을 고려하면 더욱 그러하다.

통상 감시·단속적 근로는 그 성격상 특정시간에 양적 또는 질적으로 근로시간과 휴게시간이 혼재되어 있어 근로시간만을 추출하는 것이 불

가능하다고 평가할 수 있다. 그런 점을 고려하여 근로기준법 제63조 제3호⁵⁹⁾는 고용노동부장관의 승인을 전제로 근로시간에 관한 규정 적용을 배제한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 판례는 감시·단속적 근로 이외에도 다양한 영역에서 포괄임금제를 허용한다. 특히 실무에서 많이 문제되는 영역은 버스운전기사가 버스회사를 상대로 미지급 임금을 청구하는 경우이다. 대법원이 최근에 선고한 판결들⁶⁰⁾에서도 근로시간 산정이 어렵다는 이유로 포괄임금제의 유효성을 인정하고 차액 지급 청구를 기각하였다. 그런데 버스운전기사가 버스회사를 상대로 미지급 임금을 청구하는 사안에서는, 특정 동시간대에 근로시간과 휴게시간이 혼재되어 있는 감시·단속적 근로가 문제되는 것이 아니라, 근로시간과 휴게시간 자체는 분리되어 있지만, 근로시간이 정확하게 몇 시간인지 산정하기 어려워 문제되는 것이다. 그렇다면 원고의 청구를 배척한다고 하더라도, 근로시간 산정이 어렵다는 이유로 포괄임금규정을 유효하다고 보아 원고의 차액 지급 청구를 그 자체로 배척할 것이 아니라, 근로시간 산정이 불가능하지 않으므로 정액금제라면 포괄임금규정 자체는 무효로 보고, 정액수당제라면 근로기준법이 정하는 기준에 미치지 못하는 범위에서 무효로 보되, 다만 임금 차액 지급을 구하는 원고가 약정 근로시간보다 많은 근로시간 동안 근로를 제공하였다는 사실을 증명하지 못하는 경우에는 그러한 이유로(주장·증명책임을 다하지 못하였다는 이유로) 배척하는 것이 타당하다고 생각한다. 만일 이러저러한 도구와 과학기술을 이용하여 근로시간 특정에 성공하고 그 특

58) 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토” 『성균관법학』 제23권, 성균관대학교 비교법연구소, 2012., 853면.

59) 제63조(적용의 제외) 이 장과 제5장에서 정한 근로시간, 휴게와 휴일에 관한 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다.

3. 감시 또는 단속적으로 근로에 종사하는 사람으로서 사용자가 고용노동부장관의 승인을 받은 사람.

60) 대법원 2020. 6. 25. 선고 2015다8803 판결, 대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다56120 판결, 대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다56120 판결 등.

정 근로시간을 전제로 계산하였을 경우 미지급 임금이 존재한다면, 이러한 경우에게까지 차액 지급 청구를 배척해서는 안 될 것이다.⁶¹⁾

4. 개선방법

현행 포괄임금제를 개선하는 방안으로는 포괄임금제를 위와 같이 엄격하게 해석하는 판례 법리를 정립하는 방안과 입법으로 포괄임금제의 성립 및 유효요건을 명시하는 방안 모두를 고려해 볼 수 있다.

기본적으로는 법령 해석의 문제이므로 일본 최고재판소와 같이 포괄임금제를 엄격하게 해석하는 판례 정립이 필요하다 할 것이다. 대법원이 꾸준히 점진적으로 포괄임금제를 엄격하게 해석하는 방향성을 유지해 왔다는 점에서 판례 정립을 통한 포괄임금제의 정상화가 어렵지 만은 않으리라 생각한다.

그러나 일본 최고재판소와 비교할 때 상대적으로 폭넓게 포괄임금제를 인정해 온 연혁을 고려할 때 판례에 의한 포괄임금제의 정상화가 그다지 수월하지 않다면 입법을 통하여 포괄임금제의 성립 및 유효요건을 명확하게 하는 방안도 함께 추진될 필요가 있다 할 것이다.

VI. 결론

포괄임금제는 근로기준법상 근로시간과 가산임금 내지 법정수당에 관한 규정을 잠탈할 우려가 큰 제도이다. 근로기준법상 근로시간과 가산임금 내지 법정수당에 관한 규정은 강행규정이므로 이러한 강행규정을 잠탈하지 않는 범위에서 제한적으로 그 유효성이 인정되어야 한다.

그렇다면 포괄임금제는 다음과 같이 운용되

어야 할 것이다.

1) 기본임금을 확인할 수 없는 정액급제는 그 자체로 무효로 보아야 한다. 기본임금을 확인할 수 없는 정액급제에서는 포괄임금으로 약정한 정액급을 기본임금으로 보고 가산임금을 산정하여야 할 것이다. 정액급제를 유효하게 해석하는 현행판례의 타당성에 관하여 재고할 필요가 있다.

2) 정액수당제에서는, 근로계약 당시뿐만 아니라 근로제공 시 및 임금지급 시에 일관하여 근로시간의 산정이 불가능한 경우라면, 포괄임금약정으로 정한 기본급과 가산임금이 그 자체로 근로기준법을 위반하지 않는 이상 포괄임금약정은 유효하다고 볼 것이다. 그러나 근로시간의 산정이 가능한 경우라면, 근로시간의 산정이 어려운지를 불문하고, 근로기준법이 정한 근로시간이나 가산임금 내지 법정수당에 관한 규정을 위반하는 범위에서는 무효이고, 무효인 범위에서 차액 지급 청구를 인정하여야 할 것이다.

3) 현행 판례 법리를 유지하면서 이러한 결론을 도출하려면, 근로자에게 불이익하지 않을 것이라는 유효요건을 고려하여 ‘근로시간의 산정이 어려운 경우’를 ‘근로시간의 산정이 불가능한 경우’로 한정적으로 해석할 필요가 있을 것이다.

이 논문이 포괄임금제에 대한 논의를 더욱 충실하게 하고, 근로시간과 가산임금 내지 법정수당에 관한 근로기준법의 강행규정성이 견지되는 방향으로 사업장의 관행이 정착되는데 한 점의 보탬이 되기를 희망한다.

61) 예컨대 1일 근로시간을 10시간으로 보고 포괄임금약정을 하였는데, 실제 근로시간을 정확히 특정할 수는 없지만 적어도 12시간 이상이라면, 최소한 1일 2시간에 해당하는 법정수당을 추가로 지급하여야 할 것이다.

< 참고문헌 >

I. 단행본

- 김형배, 「노동법」 제26판, 박영사, 2018.
- 노동법실무연구회, 「근로기준법주해III」 제2판, 박영사, 2020.
- 임종률, 「노동법」 제19판, 박영사, 2021.
- 하갑래, 「근로기준법」 전정 제25판, 중앙경제사, 2013.
- 荒木尙志, 「労働法」第三版, 有斐閣, 2016.

II. 논문

- 강성태, “포괄임금제의 노동법적 검토” 「노동법연구」 제26호, 서울대학교 노동법연구회, 2008.
- 김기선, “포괄임금제와 근로시간의 기록·관리” 「법과 정책연구」 제20집, 한국법정책학회, 2020.
- 김도형, “포괄임금약정에 관한 판례 법리의 검토” 「노동판례 비평」 제15호, 민주사회를 위한 변호사 모임, 2011.
- 김진석, “포괄임금계약의 허용범위” 「노동법실무연구」 제1권, 사법발전재단, 2011.
- 김홍영, “포괄임금제 법리의 새로운 검토” 「성균관법학」 제23권, 성균관대학교 비교법연구소, 2012.
- 김홍영, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나, 2019. 12.
- 문형배, “포괄임금약정과 근로기준법 제61조” 「판례연구」 제11집, 부산판례연구회, 2000.
- 박순영, “근로기준법상 근로시간의 규제와 포괄임금제” 「대법원판례해설」 제83호, 법원도

서관, 2010.

- 송명호, “포괄임금계약에 관한 고찰” 「인권과 정의」 제347호, 대한변호사협회, 2005. 7.
- 이광선, “포괄임금 약정의 효력과 문제점” 「저스티스」 통권 제141호, 2014.
- 이석, “포괄임금제 토론문”, 대법원 노동법실무연구회 세미나, 2019. 12.
- 임상민, “포괄임금약정의 성부와 유효성, 대상판결: 대법원 2020. 2. 6. 선고 2015다233579, 233586 판결” 「노동법실무연구」, 노동법실무연구회, 2021.
- 정동관 외, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, 한국노동연구원, 2016.
- 정재현, “포괄임금제의 실태 및 개선방안 연구”, 한국노동연구원, 2016.
- 조임영, “포괄임금제에 의한 임금지급계약의 성립요건” 「노동법률」 제95호, 중앙경제사, 1999.
- 최석환, “일본의 근로시간 제도개혁과 포괄임금제” 「아주법학」 제12권 제2호, 아주대 법학연구소, 2018.
- 하갑래, “포괄임금제의 내용과 한계” 「노동법학」 제29호, 한국노동법학회, 2009.
- 홍준호, “포괄임금제의 유효성과 최소기준의 원칙”, 대법원 노동법실무연구회 세미나, 2019. 12.

III. 기타

- 네이버 인터넷 기사
<https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=018&aid=000261797>

주제어 : 포괄임금제, 포괄임금약정, 근로기준법, 강행규정, 근로시간, 가산임금, 법정수당, 정액급제, 정액수당제, 근로시간 산정이 어려운 경우, 근로시간 산정이 불가능한 경우, 명시적 포괄임금약정, 묵시적 포괄임금약정, 차액 지급 청구, 감시·단속적 근로

Keywords : comprehensive wage system, comprehensive wage agreement, Labor Standards Act, mandatory rule, working hour, working

hour, additional wage, legal allowance, fixed total wage system, fixed allowance system, case where it is difficult to calculate working hours, case where it is impossible to calculate working hours, express comprehensive wage agreement, implied comprehensive wage agreement, wage difference claim, surveillance or intermittent labor